

B

ZAITUN BINTI ABDUL MANAF

(Sebagai sahabat wakil dan penjaga kepada Suraya binti Othman (K/P No:730315-14-5226)

lwn

DANIAL BIN MOHD YUSOF

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 22 April 2022 bersamaan 20 Ramadan 1443H]

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0139-2021

[Semakan Perintah Permohonan Injunksi di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon: Encik Ahmad Badri bin Hj. Idris (Tetuan Ahmad Nurul & Associates)

Pegum Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan kes Permohonan Untuk Mendapatkan Injunksi Bagi Tegahan Melawat Dan Bersama secara *inter-parte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam dalam Kes Permohonan No. 10100-005-0086-2021 pada 18/11/2021.

[2] Melalui Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan yang diikrarkan pada 16/12/2021 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti mana berikut –

- i. Bahawa suatu semakan dibuat terhadap keputusan Yang Arif Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Selangor pada 18/11/2021 yang terus membuat keputusan dengan menolak Permohonan Interim pihak Pemohon dalam Permohonan No: 10100-005-0086-2021 serta mengawardkan kos RM5,000.00 kepada Responden, tanpa membenarkan pihak-pihak memfailkan hujahan bertulis kerana keputusan tersebut adalah suatu “*irregularity of proceeding*”;
- ii. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan prosedur kerana tarikh 18/11/2021 bukan merupakan tarikh keputusan dan kedua-dua pihak Pemohon dan Responden tidak hadir;
- iii. Tarikh 18/11/2021 tersebut hanya merupakan tarikh sebutan yang pertama di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan kedua-dua pihak, terutamanya Pemohon baru melengkapkan dan memfailkan Affidavit Balasan pada 17/11/2021;
- iv. Apa-apa relif yang difikirkan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Pemohon dalam kes ini adalah ibu yang bertindak sebagai sahabat wakil (*Next of Kin*) dan penjaga kepada Suraya binti Othman (Suraya). Manakala Responden pula merupakan menantu kepada Pemohon dan suami kepada Suraya.

[4] Suraya dan Responden telah berkahwin pada 07/11/1999 di Selangor. Hasil perkahwinan pihak-pihak dikurniakan 2 orang anak yang masing-masing berusia 19 dan 16 tahun sewaktu kes permohonan injunksi difailkan.

[5] Pada 16/12/2008 Suraya yang ketika itu sedang sarat mengandung anak ketiga, telah mengalami serangan sawan dan masalah jantung sehingga kemudiannya membawa kepada kerosakan kekal otak yang dikenali sebagai "*amniotic fluid embolism with pulmonary infarction with severe hypoxic ischaemic encephalopathy*". Selepas beberapa hari menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh, Suraya telah dibawa pulang ke rumah Pemohon di Shah Alam, Selangor.

[6] Pada 07/04/2016 Responden telah memfailkan suatu permohonan bagi mengambil dan membawa keluar Suraya dari rumah Pemohon melalui Kes Saman No: 10300-099-0226-2016. Lanjutan daripada itu pada 16/06/2020 Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah mengeluarkan perintah-perintah sebagaimana berikut :

- i. *Mahkamah memerintahkan bahawa Defendan Kedua, Zaitun binti Manaf dan Defendan Ketiga, Aminah binti Othman adalah berhak untuk menjaga dan menguruskan Defendan Pertama Suraya binti Othman.*

- ii. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bersama dengan Defendan Pertama diberikan kepada Plaintiff sebagai suami pada setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad dengan dimaklumkan awal kepada Defendan Kedua dan Defendan Ketiga sekurang-kurangnya 6 jam sebelum lawatan dijalankan.*

[7] Seterusnya pada 25/02/2021, Pemohon telah memfailkan suatu Permohonan Injunksi bagi maksud menegah dan menghalang Responden melawat dan bersama dengan Suraya melalui Kes Permohonan No. 10100-005-0086-2021 dengan alasan Pemohon dan Suraya adalah golongan yang berisiko tinggi terkena jangkitan Covid-19. Berdasarkan permohonan tersebut, pada 18/11/2021 Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah menolak permohonan tersebut dengan kos sebagaimana terma yang berikut :

- i. *Mahkamah memerintahkan permohonan Pemohon adalah ditolak.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan kos sebanyak RM5,000.00 dibayar oleh Pemohon kepada pihak Responden.*

[8] Tidak berpuas hati dengan keputusan serta perjalanan kes tersebut, maka Pemohon memfailkan tindakan ini.

Alasan Semakan

[9] Bagi menyokong permohonan semakan ini, Pemohon telah mengemukakan lima (5) alasan sebagaimana yang terkandung dalam afidavit bertarikh 16/12/2021 sebagaimana berikut –

- i. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila terus memberikan keputusan pada 18/11/2021 tanpa membenarkan pihak-pihak memfailkan hujahan bertulis masing-masing.
- ii. Tarikh 18/11/2021 ialah tarikh sebutan yang biasa sahaja dan pihak-pihak baru melengkapkan afidavit terutamanya Pemohon yang baru memfailkan Afidavit Balasannya pada 17/11/2021.
- iii. Kedua-dua pihak tidak dimaklumkan bahawa tarikh tersebut adalah tarikh keputusan dan Pemohon dan Responden sendiri kedua-duanya tidak hadir.
- iv. Bahawa keputusan yang wujud pada tarikh tersebut bersifat "*judgmental*" semata-mata tanpa merujuk kepada apa-apa hujahan bertulis serta ikatan autoriti pihak-pihak.
- v. Pihak-pihak telah dinafikan hak asasi (fundamental right) apabila tidak dibenarkan memfailkan hujahan undang-undang.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[10] Sukacita untuk kami tegaskan bahawa sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar diambil mudah tanpa alasan yang kukuh menurut undang-undang. Hal ini kerana proses semakan adalah bertujuan menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak.

[11] Ini bermakna apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman bagi memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[12] Bagi menentukan sama ada kes ini boleh disemak atau tidak, kami telah merujuk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 – *Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah* yang menggariskan kriteria-kriteria sesuatu kes permohonan semakan. Dalam konteks Permohonan Semakan ini, peraturan 5 dan 7 adalah relevan. Sebagai panduan kami perturunkan kedua-dua peraturan yang dimaksudkan.

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

[13] Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Lihat kes Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah [2013]JH36(2), Sa'diah binti Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2), Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2) dan Maya binti Ahmad Fuad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2), Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011 dan Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[14] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan autoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan. Bagi tujuan tersebut kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No. 10100-005-086-2021.

[15] Setelah penelitian dibuat kepada rekod prosiding kami mendapati kronologi kes adalah sebagaimana berikut :

25/02/2021 : Kes Permohonan Injunksi difailkan oleh Pemohon

17/03/2021 : Sebutan kali pertama di hadapan Penolong Pendaftar dan pihak-pihak diarahkan memfailkan afidavit jawapan pada 07/04/2021 dan Afidavit Balasan pada 28/04/2021. Mahkamah tetapkan 05/05/2021 untuk sebut semula. Pihak-pihak dikecualikan hadir sepanjang prosiding sebutan.

05/05/2021 : Sebutan kali kedua di hadapan Penolong Pendaftar secara atas talian. Pihak-pihak telah mohon tarikh lain untuk pemfailan afidavit-afidavit. Mahkamah tetapkan pada 06/07/2021 untuk sebut semula.

07/05/2021 : Responden failkan Afidavit Jawapan.

29/06/2021 : Mahkamah memaklumkan melalui SMS prosiding sebutan yang dijadualkan pada 06/07/2021 ditangguhkan ke 08/09/2021.

26/08/2021 : Mahkamah memaklumkan melalui SMS prosiding sebutan yang dijadualkan pada 08/09/2021 ditangguhkan ke 18/11/2021.

17/11/2021 : Pemohon memfailkan Afidavit Balasan.

18/11/2021 : Mahkamah membuat keputusan.

[16] Merujuk kepada kronologi di atas kami mendapati kesemua pliding telah dilengkapkan pada 17/11/2021. Manakala tarikh tangguhan 18/11/2021 yang diberikan secara SMS tidak dinyatakan sama ada untuk sebutan atau keputusan. Semasa prosiding 18/11/2021 Peguam Syarie kedua-dua pihak telah hadir dan memaklumkan kepada Mahkamah bahawa kesemua *pliding* telah sempurna dan memohon untuk memfailkan hujahan bertulis serta autoriti secara serentak. Permohonan ini tidak dibantah oleh Peguam Syarie Responden. Walau bagaimanapun Yang Arif Hakim Bicara telah tidak memberi perhatian kepada permohonan tersebut sebaliknya terus membuat keputusan menolak permohonan Pemohon dengan kos.

[17] Di dalam penghakiman ringkasnya, Yang Arif Hakim Bicara memberikan alasan bahawa ketidakhadiran Pemohon dan Responden pada tarikh tersebut telah menyebabkan Mahkamah tidak dapat memeriksa afidavit-afidavit pihak-pihak menurut seksyen 118 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Selain itu Pemohon juga didapati tidak mempunyai *locus standi* untuk

bertindak bagi pihak anaknya dalam permohonan injunksi. Manakala dari sudut pemfailan hujah pula, Yang Arif Hakim Bicara menyatakan bahawa Mahkamah tidak terikat untuk membenarkannya kerana Mahkamah perlu meneliti permohonan pihak-pihak terlebih dahulu sebelum apa-apa arahan lanjut diberikan.

[18] Berdasarkan permohonan semakan ini, alasan utama yang dibangkitkan adalah berkaitan kegagalan Yang Arif Hakim Bicara untuk memberi ruang dan peluang kepada pihak-pihak untuk memfailkan hujahan sahaja. Oleh yang demikian ulasan kami hanya akan menjurus kepada persoalan adakah tindakan Yang Arif Hakim Bicara tersebut adalah suatu tindakan yang menyebabkan berlakunya kecacatan dalam proses perbicaraan serta bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak?

[19] Bagi memutuskan isu ini kami merujuk kepada Seksyen 126 (4), (5) dan (6) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan susunan ucapan semasa pendengaran kes khususnya pengemukakan hujah oleh pihak-pihak dalam perbicaraan seperti berikut-

Seksyen 126. Susunan ucapan

*(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim **hendaklah** meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.*

*(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim **hendaklah** meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.*

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan mana-mana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apa-apa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya.

[20] Berdasarkan peruntukan subseksyen 126 (4) dan (5) di atas adalah jelas menunjukkan bahawa pihak-pihak mempunyai hak di sisi undang-undang untuk mengemukakan hujah masing-masing sama ada secara lisan ataupun bertulis sebelum pihak-pihak menutup kes. Yang Arif Hakim Bicara pula hendaklah memastikan pihak-pihak mengemukakan hujah setelah keterangan masing-masing dibentangkan di Mahkamah.

[21] Dalam konteks semakan ini, kami dapati pihak-pihak telah membentangkan kes mereka melalui Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan dan tidak melalui keterangan lisan. Walau bagaimanapun diakhir kes Mahkamah Bicara telah tidak membenarkan permohonan Pemohon untuk mengemukakan hujah dan autoriti sedangkan hujah adalah hak yang termaktub di dalam undang-undang dan menjadi satu keperluan undang-undang untuk membantu Yang Arif Hakim Bicara membuat keputusan yang tepat.

[22] Bagi menjelaskan fungsi sebenar penghujahan ini sukacita kami kemukakan pandangan Panel Rayuan Syariah Negeri Melaka di dalam kes *Shariah binti Omar lwn Nazaruddin bin Ramli, Kes Mal (Semakan) No: 10000-003-0005-2012 [tidak dilaporkan]* yang telah mengulas mengenai keperluan hujah di dalam sesuatu kes iaitu:-

"Dari sudut fungsi proses penghujahan dalam perbicaraan, ia semata-mata untuk menarik perhatian Hakim Bicara terhadap fakta yang dibentangkannya. Ia juga boleh menarik perhatian Hakim Bicara agar merujuk kepada otoriti-otoriti yang dikemukakan dengan tujuan merit kes berpihak kepadanya. Namun, hujah pihak-pihak pula tidak boleh diterima secara terus oleh Hakim Bicara tanpa melalui proses ujian berasaskan kehendak sebenar undang-undang dan hukum syarak. Dengan itu, bolehlah dibuat kesimpulan bahawa hujah pihak-pihak merupakan suatu proses membantu Hakim Bicara sebelum membuat keputusan dan bukan berupa sumber utama para Hakim membuat keputusan. Rujukan

fakta berkaitan perkara yang dituntut mestilah kepada keterangan Pemohon dan Respondan serta keterangan sokongan berupa keterangan saksi atau dokumen. Hanya melalui sumber-sumber tersebutlah Hakim akan menilai samada suatu tuntutan atau permohonan boleh diluluskan atau tidak. Atas dasar itulah dalam penghakiman para Hakim lazim dinyatakan bahawa hujah sesuatu pihak itu diterima atau ditolak.”

[23] Berbalik kepada situasi dalam kes semakan di hadapan kami ini, dengan mengambil kira Afidavit Balasan yang baru difailkan oleh Pemohon sehari sebelumnya iaitu pada 17/11/2021 serta ketiadaan makluman berkenaan status kes tersebut sama ada untuk sebutan atau keputusan, maka tarikh 18/11/2021 telah difahami oleh pihak-pihak sebagai tarikh sebutan sahaja setelah dua kali penangguhan diberikan oleh Mahkamah sebelumnya. Oleh yang demikian pada hemat kami dan secara amalnya tarikh tersebut sewajarnya ditetapkan untuk sebutan terlebih dahulu bagi membolehkan Mahkamah mendapat pengesahan daripada pihak-pihak berhubung dengan status *pliding* yang difailkan serta untuk mendapat kepastian sama ada pihak-pihak berhasrat untuk memfailkan hujahan atau sebaliknya.

[24] Sungguhpun hujahan bukan sesuatu yang mandatori dalam sesuatu kes permohonan, tetapi dengan menafikan hak pihak-pihak untuk berhujah dan mengemukakan autoriti adalah sesuatu yang tidak mencerminkan keadilan sebenar pada ketika adanya permohonan daripada Pemohon untuk berbuat demikian. Adalah lebih cermat dan selamat sekiranya ruang untuk pihak-pihak berhujah diberikan kerana ianya mampu membantu Yang Arif Hakim Bicara untuk mendapat pencerahan berkaitan persoalan undang-undang yang dibangkitkan dalam alasan penghakiman ringkasnya. Hal ini adalah bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW

ketika mengutuskan Saidina Ali menjawat jawatan Qadi ke Yaman di mana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما
سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertimana yang pertama.”

[25] Nas tersebut adalah turut selari dan bertepatan dengan maxim perundangan *audi alteram partem* yang bermaksud mendengar keterangan kedua belah pihak, iaitu kedua-dua belah pihak diberikan hak yang sama untuk mengemukakan keterangan dan hujah mereka di hadapan hakim. Melalui prinsip ini, seseorang hakim dapat menghakimi sesuatu kes dengan adil dan saksama dan bukan semata-mata berdasarkan keterangan satu pihak saja yang boleh mengundang risiko kepada keputusan berat sebelah.

[26] Tindakan Yang Arif Hakim Bicara yang terus menolak permohonan Pemohon dan mengenakan kos sebanyak RM 5,000 untuk dibayar kepada Responden tanpa ada sebarang permohonan serta justifikasi pada hemat kami adalah suatu kecacatan material yang menjejaskan keadilan. Situasi ini bertepatan dengan kehendak Peraturan 5 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang telah kami nyatakan bagi membolehkan sesuatu keputusan kes disemak dan dinilai semula.

[27] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, maka kami membuat kesimpulan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak permohonan Pemohon untuk mengemukakan hujah dan autoriti. Oleh yang demikian, dengan berpaksikan

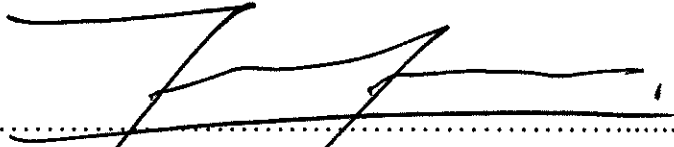
keadilan bagi kedua-dua pihak maka terdapat keperluan untuk kami campur tangan untuk memperbetulkan kekhilafan tersebut dengan memberi ruang kepada pihak-pihak untuk mengemukakan hujahan dan autoriti-autoriti yang berkaitan sebelum Mahkamah membuat pertimbangan sama ada untuk menerima atau menolak permohonan injunksi Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10100-005-0086-2021, MAKA kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

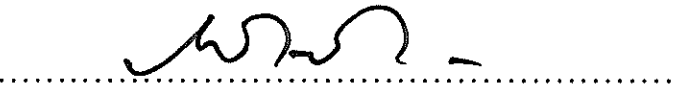
- [1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA**.
- [2] Perintah Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam Kes Permohonan No: 10100-005-0086-2021 pada 18/11/2021 **DIBATALKAN**.
- [3] Bahawa pihak-pihak dibenarkan untuk memfailkan hujahan dan prosiding Kes Permohonan No: 10100-005-0086-2021 diputuskan semula oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang lain.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor